

1509769-36.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1509769-36.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2085079/2022 - 12º D.P. PARI, 23916027 - 12º D.P. PARI, 2085079 - 12º D.P. PARI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO MARIO SILVA ARAUJO

Vítima:

SAUDE PUBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 24 de outubro de 2022, às 16:30h, na sala de audiências da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, pelo meio previsto no Comunicado CG nº 284/2020, com utilização da plataforma Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcus Alexandre Manhães Bastos, comigo Assistente Judiciário ao final assinado, compareceram a Promotora de Justiça Dra. Letícia Stuginski Stoffa e o réu JOÃO MARIO SILVA ARAUJO, acompanhado do Defensor Público do Estado Dr. Luis Fernando Vilas Boas Bonachela. Presentes as

testemunhas MARIA DALVA FERREIRA CARNEIRO (PC) e GREGORIO JUNITI YSHICO (PC). O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência virtual nos autos do processo criminal em epígrafe, com as formalidades legais, e foram então ouvidas as testemunhas presentes, cujos depoimentos foram colhidos por meio audiovisual, pelo sistema de captação de áudio e vídeo do Microsoft Teams. Em seguida, ao réu foi dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com o Defensor Público que o assiste antes da realização do ato. Por ocasião do interrogado, o acusado exerceu seu direito Constitucional de permanecer em silêncio, gravado pelo sistema de gravação de áudio e vídeo do Microsoft Teams. Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, pelo MM. Juiz de Direito foi declarada encerrada a instrução. Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, foi dito: MM. Juiz, requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual. Dada a palavra ao Dr. Defensor Público, pelo réu, foi dito: MM. Juiz, D. Promotora de Justiça, JOÃO MARIO SILVA ARAUJO, foi denunciado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, pois, em tese, trazia consigo, vendia e guardava, para fins de tráfico, 05 (cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 3,65g (três gramas e sessenta e cinco decigramas).do MP requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia). A defesa entende que é o caso de absolvição do réu por falta de provas de autoria delitiva, pois João Mario não foi previamente visualizado praticando atos compatíveis com o comércio de drogas, Apesar de um potencial consumidor ter sido abordado, não foi ouvido nesta audiência. Além disso, não há testemunhas ouvidas em juízo para além dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu. É o caso, portanto, de aplicação do princípio da presunção de inocência, com a absolvição do réu por insuficiência de provas de autoria delitiva. Como cediço, o inquérito policial é peça meramente informativa que se destina a autorizar a deflagração da ação penal. Logo, não pode servir de lastro ao juízo condenatório, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Hodiernamente, com a exigência do contraditório e da ampla defesa, as provas produzidas na fase pré-processual destinam-se ao convencimento do Ministério Público e não do juiz. Por essa razão, as provas devem ser repetidas na fase instrutória da ação penal. Daí a previsão expressa do art. 155 do Código de Processo Penal, conferida pela Lei 11.690/2008 (consigne-se aqui novamente o prequestionamento da matéria). A reforma na lei processual penal buscou reforçar a importância do respeito ao contraditório na produção probatória. O referido dispositivo estabeleceu que o juiz deverá formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, excluiu-se, com isso, a possibilidade de se utilizar tão somente elementos informativos colhidos na investigação. Vê-se a jurisprudência: Provas (validade e eficácia). Sentença condenatória. Fundamento exclusivo: provas produzidas no inquérito (nulidade). Violação do contraditório (ocorrência). 1. O inquérito policial é procedimento preparatório que apresenta conteúdo meramente informativo com o fim de fornecer elementos tendentes à abertura da ação penal.2. A prova, para que tenha valor, deve ser feita perante juiz competente, com as garantias de direito conferidas aos indiciados e de acordo com as prescrições estabelecidas na lei. 3. As provas produzidas ao longo da fase inquisitiva têm validade e eficácia na formação da convicção do juiz tão-somente se confirmadas por outros elementos colhidos durante a fase instrutória judicial. Do contrário, não se prestam a fundamentar o juízo condenatório, sob pena de violação do contraditório. 4. É trabalho da acusação transformar os elementos do inquérito em elementos de convicção do juiz. 5. Habeas corpus concedido para restabelecer a sentença absolutória. (HC 32.083 – MG, Rel. Nilson Naves, j. em 07.05.2005). Processual Penal. Inquérito policial (procedimento preparatório). Provas (validade e eficácia). Sentença condenatória. Fundamento exclusivo: provas produzidas no inquérito (nulidade). Violação do contraditório (ocorrência).1. O inquérito policial é procedimento preparatório que apresenta conteúdo meramente informativo com o fim de fornecer elementos tendentes à abertura da ação penal. 2. A prova, para que tenha valor, deve ser feita perante juiz competente, com as garantias de direito conferidas aos indiciados e de acordo com as prescrições estabelecidas na lei. 3. As provas produzidas ao longo da fase

inquisitiva têm validade e eficácia na formação da convicção do juiz tão-somente se confirmadas por outros elementos colhidos durante a fase instrutória judicial. Do contrário, não se prestam a fundamentar o juízo condenatório, sob pena de violação do contraditório. 4. É trabalho da acusação transformar os elementos do inquérito em elementos de convicção do juiz. 5. Habeas corpus concedido para restabelecer a sentença absolutória. (HC 36.813 – CE, Rel. Nilson Naves, J. 07.04.2005).

Subsidiariamente, caso se entenda que o réu estava em posse das drogas apreendidas, requer-se a desclassificação da conduta imputada para a prevista no artigo 28 da Lei de drogas. Cumpre considerar que a quantidade de drogas apreendidas é compatível com a posse de drogas para uso pessoal. Caso se entenda pela condenação pela prática de tráfico de drogas, requeiro a) a fixação da pena-base no mínimo legal, já que não foi apreendida quantidade significativa de drogas e a natureza da droga não é digna de nota. c) requeiro o afastamento do aumento em razão da reincidência caso esse fator seja usado para afastar o redutor art. 33, parágrafo quarto, da Lei de drogas, a fim de evitar “bis in idem” e e) a fixação do regime menos gravoso para início de cumprimento de pena, já que a gravidade abstrata do delito é insuficiente para a fixação de regime mais gravoso do que a lei recomenda f) a possibilidade de apelo em liberdade, já que restam ausentes os requisitos da prisão cautelar h) por fim, os benefícios da justiça gratuita. Por fim, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida sentença condenatória, nos termos seguintes: JOÃO MÁRIO SILVA ARAÚJO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de março de 2022, por volta das 13h52, no Largo do Arouche, nº 1.000, bairro República, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, vendia e guardava, para fins de tráfico, 05 (cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 3,65g (três gramas e sessenta e cinco decigramas), substância esta entorpecente, capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De acordo com a denúncia, o acusado estava no Largo do Arouche durante a madrugada, local conhecido como ponto de venda de drogas. Em determinado momento, o acusado, que ali estava parado, foi procurado por outro indivíduo, entregando-lhe certa quantia em dinheiro em troca de algumas porções de droga. Consta que a conduta do acusado e do usuário foi observada por policiais civis que transitavam pelo local, decidindo estes por abordar os dois. Em revista, os policiais encontraram, nas mãos do usuário, três papелotes contendo cocaína. Já na posse do acusado, em suas vestes, localizaram outros dois papелotes de cocaína, além da quantia de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), em espécie. Narra a denúncia que informalmente inquirido, o denunciado confessou a traficância. Já o outro indivíduo de pronto admitiu ser usuário, dizendo que havia acabado de adquirir os entorpecentes de João pelo valor de R\$20,00 (vinte reais) a porção, versão que o denunciado não contestou. Por ocasião da análise judicial de regularidade formal do flagrante, após regular homologação, a prisão foi convertida em preventiva. Após notificação do acusado, a Defensoria Pública apresentou defesa preliminar, de fls. 74-75. A denúncia foi recebida, à fls. 76-81. Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Policiais Civis Maria Dalva Ferreira Carneiro e Gregório Juniti Yshico. Ao final, o acusado foi interrogado, ocasião na qual exerceu o seu direito constitucionalmente assegurado de permanecer em silêncio. Encerrada a instrução processual, as partes se manifestaram em alegações finais, em audiência. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Da cuidadosa análise do processado, verifica-se a procedência do pedido inicial, impondo-se a condenação do acusado em razão da prática do crime de tráfico de drogas, porquanto comprovada a materialidade e autoria delitiva. A materialidade delitiva está comprovada, a partir do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1), do Boletim de Ocorrência (fls. 19-21), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13), do Laudo de Exame Químico-toxicológico definitivo (fls. 63-65), bem como pelas provas orais colhidas em juízo. A autoria também está devidamente comprovada. Ao ser ouvida em juízo a testemunha Policial Civil Maria Dalva Ferreira Carneiro relatou que o local da detenção do acusado é ponto no qual o tráfico de drogas é recorrente. Conhece bem esse ponto. Estavam em diligências, deixaram

a viatura e circularam para verificar a movimentação. Em certo instante observaram

o acusado e outra pessoa realizando troca de dinheiro por algum objeto, efetuaram abordagem. O acusado estava entregando a droga e o outro estava adquirindo. Ao que se recorda, havia dois pinos no bolso dele e 120,00. O comprador disse que havia acabado de adquirir a droga do acusado. No mesmo sentido, o relato do Policial Civil Gregório Juniti Yshico, a relatar que estava com a policial Dalva no largo do Arouche e viram o acusado comercializando drogas, pegando dinheiro e entregando algo que imaginaram se tratar de droga. Efetuaram abordagem e ao que se recorda ele tinha cocaína e dinheiro. O outro abordado disse que havia adquirido cocaína do acusado. Ao ser interrogado, o acusado optou por permanecer em silêncio. Pois bem, os relatos dos policiais, que afirmaram ter presenciado a prática de atos de venda de drogas, em contexto no qual o acusado teria efetuado entrega de drogas para terceira pessoa, recebendo dinheiro em contrapartida, são suficientes a atestar a autoria do delito. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos Policiais Cíveis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Neste sentido, verifique-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7). A finalidade de narcotraficância foi evidenciada por alguns indícios irrefutáveis, acima de tudo, pelas circunstâncias da prisão e pelos depoimentos das testemunhas. Esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros. Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto à apreensão do entorpecente, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade. Desta forma, a prova dos autos confirma a traficância, não havendo que se falar em eventual pretensão desclassificatória, para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, não se vislumbra nenhum fator que justifique a exasperação da pena-base, de tal maneira que fica estabelecida no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o valor unitário no menor patamar. Na segunda fase, não se verifica nenhuma agravante ou atenuante da pena a considerar. Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O acusado é primário, não ostenta antecedentes criminais desabonadores, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas na lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena prevista no preceito secundário do "caput" do artigo 33. Ressalte-se que, a despeito de ostentar condenação recente, transitada em julgado, o trânsito em julgado é posterior aos fatos destes autos e, na perspectiva deste Juízo e com o devido respeito ao entendimento da Ilustre Promotora de Justiça, não pode ser considerado para fins de vedação à incidência da causa de diminuição da pena de que ora se cuida. Tenho por certo que não seria adequado impedir o privilégio em casos tais, sobretudo a se considerar que caso a presente demanda tivesse corrido em tempo menor e a sentença fosse proferida antes do trânsito em julgado, não haveria nenhum impedimento à incidência do redutor da pena. Ademais, colaciona-se precedente jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 3.

“A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal” (HC 534.671/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019). 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial para estabelecer a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos, a cargo do Juízo da Execução. (AgRg no AREsp 1899869/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021). Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena base de dois terços, chegando ao resultado de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e seiscentos e seis) dias-multa. Diante do montante da pena aplicada, sendo o acusado primário, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Atento à pena estabelecida e à primariedade do acusado, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado JOÃO MÁRIO SILVA ARAÚJO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, além da multa originária no valor de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo. A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida. Considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, não se justifica a manutenção da prisão preventiva, devendo ser facultado ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se Alvará de Soltura clausulado. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária, ficando neste ato expressamente deferida a gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no “Rol dos Culpados”. Publicada em audiência, sendo as partes dela intimadas nesta ocasião. Nada mais. Não havendo óbice na utilização de sistema audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados pelo Microsoft Teams, acostados aos autos por meio de certidão lavrada após o presente termo de audiências. Lido e achado conforme, este termo de audiência vai devidamente assinado, digitalmente, pelo MM. Juiz de Direito, consoante disposto no artigo 1.269 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Eu, Rogério Teixeira Fernandes, digitei.